

1501078-22.2022.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/10/2022

... o acusado cometido o crime de tráfico de entorpecentes em companhia do adolescente Jeferson, segundo depoimento dos guardas, deve incidir a causa de aumento especial prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, dado o envolvimento da menor na traficância. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tj.sp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501078-22.2022.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2220305/2022 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 26733803 -

DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2220305 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

JOAO VITOR APOLINARIO

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP c/c Art. 40 "caput", III do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

19/10/2022

Réu Preso

Em 19 de outubro de 2022, às 14:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: o representante do Ministério Público, na pessoa do DRA. FABIANA MARIA NOVAES CANATELLI RODRIGUES, DD^a. Promotora de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu JOAO VITOR APOLINARIO, bem como sua Defensora Técnica, DRA. Cristiane Cardoso Soares OAB 284637/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual a vítima as testemunhas Luiz Andrade Silva Junior (GCM) e Eduardo Leopoldo Ambold (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com a sua Defensora. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquirições fossem por elas iniciadas. Nada obstante o encerramento do Sistema Remoto de Trabalho e do Sistema Escalonado de Retorno ao Trabalho Presencial, a presente

audiência foi realizada por meio de videoconferência, através da plataforma Microsoft Teams, conforme disciplina já estabelecida pela Corregedoria Geral da Justiça no Comunicado CG nº 284/2020 (cf. artigo 8º do Provimento CSM nº 2651/2022). Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu JOÃO VITOR APOLINÁRIO, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, eis que, em 12 de agosto de 2022, por volta das 17h28, na rua José Orsi, nº 190, Jardins de Tatuí, nesta cidade e Comarca de Tatuí, previamente ajustado, agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com o adolescente Jeferson Mateus de Oliveira Ribeiro, tinha em depósito e guardava, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 34 porções de cocaína, com peso bruto aproximado de 32 gramas, e 05 porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "maconha", com peso bruto aproximado de 4,5 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, o acusado praticava o tráfico de drogas com o adolescente, sendo que dividiam as tarefas na empreitada criminosa. Para tanto, JOÃO VITOR e Jeferson Mateus guardavam as drogas nas proximidades do "ponto de venda", a fim de dificultar a apreensão. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina - no bairro Vila Angélica - quando receberam a informação de que dois indivíduos estavam praticando o comércio ilegal. A informação também indicava as vestes e os nomes dos agentes, bem como apontava que os entorpecentes eram guardados na caçamba de coleta de lixo. Os Guardas avistaram o acusado e o adolescente, juntos, ao lado da caçamba, porém, ao notarem aproximação da viatura, saíram caminhando para lados opostos. Houve a abordagem e, com o adolescente, foi apreendido aparelho de telefonia celular. Na caçamba de lixo foi localizado o saco plástico contendo 34 porções de cocaína e 05 porções de "maconha". O réu foi notificado (fls. 89) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 94/96). Assim, por decisão proferida no dia 11 de outubro de 2022, foi recebida a denúncia (fls. 108/110). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas e, ao final, interrogado o réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia. De outra banda, a Defesa Técnica pugnou pela absolvição do réu, alegando insuficiência de provas, bem como, subsidiariamente, pela concessão de todos os benefícios legais a incidir em fase de dosimetria da pena e fixação do regime prisional inicial. Certidões a fls. 42/44. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido acusatório comporta procedência, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, c.c. art. 40, VI, da Lei 11.343/06. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), pelo auto de constatação preliminar (fls. 09/10), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 83/85) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 15), afirmou que, na data dos fatos, estava na porta de sua casa quando os Guardas Municipais chegaram e o abordaram. Na sequência, os guardas se dirigiram até uma caçamba na esquina de sua rua e, ao voltarem, disseram que localizaram drogas e que estas seriam dele. Disse que não estava com nenhum entorpecente nem com dinheiro. Disse que o menor Jeferson não estava junto dele e foi abordado em outro local no final da rua. Afirmou que conhece Jeferson somente de vista. Perguntado se possui alguma inimizade ou desavença com alguém para que imputassem a propriedade das drogas, disse que não. Em juízo, disse que estava sentado em frente de casa com sua namorada que está

gravida e com Patrick. Jeferson estava do outro lado da rua. Ambos estavam distantes da caçamba. Só na delegacia apresentaram as drogas que estariam na caçamba. Tinha passado uns moleques na rua, uns moreninhos e disseram que a viatura estava se aproximando – refere-se a Jeferson e outro moleque. Viu que uma viatura abordou o Jeferson. E outra viatura o abordou. Jeferson estava com uma pochete e não sabe dizer se a droga era dele. Quanto a denúncia anônima, tem um sobrinho seu envolvido com o tráfico, com o mesmo sobrenome, e talvez a denúncia fosse referente a ele. Tem passagem na vara da infância e juventude. Esta respondendo a um processo por uso. Sua companheira está grávida. Trabalhava na lavoura de batata. Há um vizinho que já brigou com seu sobrinho e quis conversar com ele, talvez esse vizinho não tenha gostado. Talvez esse vizinho tenha feito a denúncia. As pessoas tem preconceito por ele ser cigano, acham que é ladrão. Não tinha luzes no cabelo na época dos fatos e além disse estava de blusa e capuz. Analisando a autodefesa do acusado – colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – resta evidente que esse negou os fatos. No entanto, não apresentou versão coerente que justificasse sua negativa de autoria, tampouco provas que demonstrassem sua inocência. De outro lado, a prova produzida nos autos revela a prática do crime narrado na exordial. Com efeito, o Guarda Civil Municipal Eduardo Leopoldo Ambold, em sede policial (fls. 11/12), afirmou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam em patrulhamento pelo bairro vila Angélica, quando receberam “denúncia” de um morador da Rua Jose Orsi, o qual relatou a equipe ter presenciado dois indivíduos, um de bermuda e camiseta azul de alcinha Jeferson, e o outro com luzes no cabelo e de alcinha Apolinário, escondendo entorpecentes em uma caçamba de coleta de lixo. Ambos já conhecidos na prática do crime de tráfico. Diante das informações, deslocaram-se junto com a equipe de canil a rua Jose Orsi e encontraram com os dois indivíduos com as mesmas características de vestimentas e físicas, parado do lado da caçamba de lixo. Esses suspeitos, ao perceberem a presença das viaturas, saíram andando em lados opostos. Jeferson foi abordado e, na revista pessoal, foi localizado um aparelho celular e nada mais. O acusado também foi abordado e, em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. Verificando a caçamba de lixo, foi localizado um saco plástico contendo 34 porções de cocaína, tipo Aricanduva e mais 5 porções de maconha. Indagados sobre os entorpecente e mercancia, os dois negaram a posse e a mercancia dos entorpecentes. Em juízo disse que já conhecia o réu pelo envolvimento com o tráfico desde a adolescência. No dia dos fatos receberam a informação de um morador da mesma rua, dizendo que tinham presenciado Apólinário e Jeferson guardando drogas numa caçamba de lixo, repassou também as vestimentas. Foram ao local e visualizaram os indivíduos ao lado da caçamba e com a aproximação eles saíram de perto da caçamba. Participou da abordagem do menor e com ele nada foi encontrado e negou qualquer envolvimento com o tráfico. Quando chegaram ao local os réus estavam juntos conversando e próximos a caçamba e quando avistaram a viatura, saíram andando para lados opostos. Já abordou o réu anteriormente. Não sabe dizer se o réu é usuário de drogas. O réu disse que era amigo de Jeferson. No momento que se aproximaram do local, visualizaram apenas o réu e o adolescente próximos a caçamba. Convergingo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Luiz Andrade Silva Junior, em solo policial (fls. 13), corroborou integralmente a versão de seu colega de corporação. Em juízo, o réu disse que já conhecia o acusado quando ela menor de idade e já tinha informações do envolvimento dele com o tráfico. No dia dos fatos receberam dneuncia de que dois indivíduos na rua Jose Orsi tinham acabado de esconder entorpecentes numa caçamba de lixo, sendo repassadas as características e os nomes dos indivíduos. No local, ambos estavam próximo a caçamba e a Romu abordou o menor. Não sabe dizer o que o adolescente disse. Já o réu informado da denúncia, negou que estivesse vendendo, que a droga não era dele. A denúncia anônima foi passada direta a equipe (não foi formalizada). Fazia parte da viatura de canil e a denúncia foi repassada para Romu. Não presenciou o réu e o adolescente comercializando. Também não os viram escondendo a droga, os viram junto a caçamba. Quando chegaram, o réu e o adolescente avistaram a viatura e se separaram. Apolinário que mora ali do lado, sentou-se perto da família dele e o menor foi para o outro lado. Não participou de abordagens do réu em que foi encontrada droga com

ele. Não se recorda do réu ter dito que era usuário. O réu ano aparentava estar sob efeito de substância entorpecente. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Nesse sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu

Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado mantinha em guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos das agentes de segurança, que narraram verossimilmente, a apreensão da droga onde o acusado estava; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 83/85), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações e forma de acondicionamento própria para a venda "a varejo" de entorpecentes; 3) a localização do acusado em local onde informação anônima descrevia que duas pessoas com as mesmas vestimentas que ele as dele e as do adolescente estariam traficando drogas; e 4) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo de drogas. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da "cocaína" em usuários depende de variados aspectos.

Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, aprendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTCrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., verbi gratia, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 83/85) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo –, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. E mais, tendo o acusado cometido o crime de tráfico de entorpecentes em companhia do adolescente Jeferson, segundo depoimento dos guardas, deve incidir a causa de aumento especial prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, dado o envolvimento da menor na traficância. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o jus puniendi, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhes imposta. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2.006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. De fato, observo que o apontamento criminal retratado a fls. 42 (Proc. 1500965-68.2022.8.26.0571) se refere a ação penal em curso e, a despeito de entendimento pessoal diverso dessa Magistrada, observo que a jurisprudência se consolidou no sentido da imprestabilidade desses registros delitivos como maus antecedentes ou para a valoração negativa em primeira fase (Súmula nº 444 do STJ). Aliás, assim também tem se posicionado a jurisprudência do E. TJSP, apontado que ações penais em curso, ainda que condenações provisórias: “embora tal circunstância denote a personalidade desregrada do acusado, não se presta a majorar a sanção inicial, a teor da Súmula 444, do Superior Tribunal de Justiça.” (TJSP; Apelação Criminal 1502727-43.2020.8.26.0037; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de

Araraquara - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/08/2021; Data de Registro: 03/08/2021). Desse modo fixo sua pena-base no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Em segunda fase, a despeito do acusado possuir menos de 21 anos à época dos fatos, deixo de aplicar a atenuante de menoridade relativa, uma vez que a pena-base foi fixada no patamar mínimo, piso abaixo do qual não se pode fixar a pena-intermediária (Súmula nº 231 do STJ). Mantenho, pois, inalterada sua pena nessa etapa. Por oportuno, convém destacar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Na terceira fase, a causa de aumento especial prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, majora sua pena em 1/6, gerando a reprimenda legal de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a qual torno definitiva, à mingua de demais causas modificadoras da pena. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, tratando-se de réu que está sendo processado criminalmente em outro feito fls. 42 (Proc. 1500965-68.2022.8.26.0571 - foi flagrado, supostamente, no exercício da traficância menos de 01 mês dos fatos apurados nos autos), elemento caracterizador de dedicação a atividades criminosas, resta inviabilizada a concessão da benesse em questão. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: "É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006." (STJ. 3ª Seção. EREsp 1.431.091-SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgado em 14/12/2016). Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, e, com fulcro no artigo 33, § 3º, c.c. art. 59, III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, considerando a diversidade de entorpecentes traficados, o envolvimento de adolescente na traficância e personalidade criminosa (fls. 42 - Proc. 1500965-68.2022.8.26.0571 - foi flagrado, supostamente, no exercício da traficância menos de 01 mês dos fatos apurados nos autos), revelando a persistência do réu na seara criminosa, o que exige a fixação do regime prisional mais severo para conter seu ímpeto delitivo. As mesmas motivações acima expostas impedem a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento

da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo Procedente a pretensão punitiva para condenar o réu JOÃO VITOR APOLINÁRIO, devidamente qualificado nos autos, no art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a prisão provisória do acusado. E mais, trata-se de réu que desde sua adolescência envolve-se com atividades ilícitas (fls. 44) e que foi flagrado, supostamente, no exercício da traficância menos de 01 mês dos fatos apurados nos autos (fls. 42 - Proc. 1500965-68.2022.8.26.0571), de modo a revelar que, acaso solto, tornará a delinquir, razão pela qual a manutenção de sua prisão cautelar é absolutamente necessária para garantir a ordem pública. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento, bem como arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intím-se o réu para que efetuem o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que os entorpecentes apreendidos já foram periciados, destruam-se as drogas na forma da lei. Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP". Pela Defensora do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 90). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe. Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se". ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA